

1502042-74.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquecetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1502042-74.2022.8.26.0616 - p.

SENTENÇA

Processo nº:

1502042-74.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

ROSILAINE FERNANDES DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ROSILAINE FERNANDES DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de drogas em 2 de setembro de 2022.

De acordo com a denúncia, no dia 2 de setembro de 2022, por volta de 01h00min, na Rua Orquídeas, altura do nº 24, Bairro Parque Viviane, nesta cidade, a denunciada trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 38 invólucros de cocaína (com peso de 3,84 gramas) e 50 invólucros de maconha (com peso de 169,83 gramas).

Narra a peça acusatória que guardas municipais realizavam patrulhamento pelos equipamentos municipais quando foram abordados por um casal, que realizaram uma reclamação acerca do barulho excessivo no local dos fatos. Ato contínuo, os guardas se deslocaram ao local, onde visualizaram a denunciada parada na entrada de um bar segurando uma sacola, a qual já havia sido presa em flagrante por membros da guarnição há 21 dias. Desse modo, os guardas abordaram a denunciada. Na sacola que ROSILAINE segurava, foi localizada a importância de R\$ 20,00, dinheiro auferido com a traficância, além das drogas acima descritas. Indagada pelos servidores públicos,

ela respondeu que vende drogas no local e, em contrapartida, ganha R\$ 150,00 por 12 horas de comercialização espúria.

A denunciada foi devidamente notificada (pág. 82) e apresentou defesa prévia (pág. 85).

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2022 (págs. 87/88).

Na fase de instrução, coletou-se a prova oral e, ao final, a ré foi interrogada.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se na insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva não merece ser acolhida.

A testemunha MICHELE LIMA DA SILVA, guarda civil municipal, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento preventivo e recebeu notícia que havia barulho excessivo no local dos fatos. Ao chegar no local, observou uma mulher com uma sacola na mão, que já tinha sido presa anteriormente por tráfico de entorpecentes. Não chegaram a fazer contato com o dono do bar. Somente a acusada foi revistada. Nenhuma outra mulher. Feita busca pessoal e identificada a acusada, nada de ilícito foi encontrado. Porém, dentro da sacola haviam 38 (trinta e oito) unidades de cocaína, 50 (cinquenta) unidades de maconha e R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Indagada, a ré informou que comercializava drogas no local e que ganhava R\$ 120,00 (cento e vinte reais) por 12 (doze) horas por dia. Em seguida, conduziu a acusada à delegacia de polícia.

A testemunha FERNANDO MENDES DE SOUZA, também guarda civil municipal, confirmou o depoimento prestado por seu colega, agregando que, patrulhando por conta da UBS e escolas, um casal parou a viatura reclamando do som. A ré já era conhecida da guarda municipal no tráfico de drogas. Havia cerca de 30 a 40 pessoas dentro do bar e começaram a dispersar. Conversou com o dono do bar. Era uma senhora. Estavam em três equipes. Somaram 6 policiais em 3 viaturas.

Enfim, ao ser interrogada, a ré ROSILAINE FERNANDES DOS SANTOS afirmou que conta com 39 (trinta e nove) anos. Quanto aos fatos, declarou que estava colocando música. Ninguém saiu correndo. O guarda municipal que funcionou como testemunha disse: "Você não ficou presa ainda, carniça? Mas hoje você vai ficar." Que eles abriram uma sacola e disseram que era dela.

Passo a valorar a prova.

Em primeiro lugar, faz-se mister registrar que a prisão em flagrante da ré foi realizada ilicitamente, já que não havia justa causa para realização de busca pessoal.

No presente caso, os guardas civis que procederam à prisão em flagrante da acusada extrapolaram os limites de suas funções, já que atuaram sem visar à proteção dos bens, serviços e instalações do Município de Itaquaquecetuba (arts. 144, § 8º, da Constituição Federal e 2º, 4º e 5º, inciso II, da Lei nº 13.022/2014).

É cediço que deve existir fundada suspeita que justifique a realização de busca pessoal, de modo que deve haver elementos concretos que impliquem suspeita de prática criminosa, não sendo permitido às guardas municipais realizar busca pessoal como decorrência de atividade de investigação criminal.

No presente caso, a atuação dos guardas municipais não se baseou em nenhuma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, mas tão somente no fato de a acusada já ter sido presa em flagrante anteriormente por membros da guarnição pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Os entorpecentes foram encontrados somente após realização de busca pessoal, o que constitui verdadeira atividade de investigação que extrapola as competências constitucionais e legais previstas para as guardas civis municipais.

Se a sacola efetivamente estava sendo segurada pela acusada, a verificação de seu conteúdo pelos guardas civis somente poderia ser realizada se houvesse justa causa, não bastando a impressão subjetiva dos guardas civis. O crime de tráfico ilícito de drogas ora imputado à acusada, embora seja crime permanente, só foi constatado depois da revista pessoal pelos guardas civis, que não são policiais, o que evidencia a irregularidade por ausência de causa justa e prévia. Nesse cenário, tem-se que a busca pessoal foi realizada em atividade ostensiva de policiamento em via pública, o que não se coaduna com as funções dos guardas civis.

A ilegalidade da busca pessoal fica evidenciada pela prova oral produzida em juízo. As testemunhas Michele Lima da Silva e Fernando Mendes de Souza declararam que, no local dos fatos, havia cerca de 30 a 40 pessoas, mas apenas a acusada foi revistada. De mais a mais, os guardas civis foram ao local em decorrência de uma reclamação por barulho excessivo, e a revista de sacolas não tem relação com isso. Dessa forma, salta aos olhos que a abordagem da acusada e a subsequente busca pessoal não tiveram relação com qualquer bens, serviços e instalações do Município de Itaquaquecetuba.

A respeito do tema, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte “apesar das investidas em contrário” por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.

2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil “em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência” estão sujeitas a rígido controle correccional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais “apesar da sua relevância” não estão sujeitas a nenhum controle correccional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar “em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais” o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento

de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora “alguns até mesmo de porte bastante diminuto “

estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais “e por isso interpretadas restritivamente “ nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara,

direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado.

Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.

12 . Recurso especial provido.

(REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

Por conseguinte, constatado que houve o desempenho de nítida atividade de investigação pelos guardas civis, que desborda da situação de flagrância, deve ser reconhecida a invalidade das provas dela decorrentes e, conseqüentemente, a ré deve ser absolvida.

Ainda que assim não fosse, igualmente seria hipótese de absolvição da ré.

A despeito da prova de materialidade delitiva estar devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado às páginas 13/14 e pelo laudo toxicológico definitivo juntado às páginas 145/147, a prova produzida durante a fase de instrução não evidenciou a autoria delitiva.

A testemunha Michele Lima da Silva declarou que no local havia de 30 a 40 pessoas e a testemunha Fernando Mendes de Souza declarou que elas começaram a dispersar quando da chegada da guarnição. A ré, por sua vez, afirmou que não segurava nenhuma sacola e que não tentou se evadir quando da chegada dos guardas civis, o que indicia que ela não tinha qualquer relação com a sacola encontrada no local, pois, se efetivamente estivesse portando drogas, teria tentado fugir quando da chegada dos guardas.

De mais a mais, verifica-se que o depoimento prestado pelas testemunhas é contraditório: enquanto Michele Lima Da Silva declarou que não chegaram a fazer contato com o dono do bar, Fernando Mendes de Souza declarou que conversou com o dono do bar. Tal contradição reduz o valor probatória desses depoimentos.

Em suma, as drogas apreendidas não estavam na posse da acusada e nenhum ato de traficância foi presenciado pelos guardas municipais.

Enfim, tampouco deve ser levada em consideração a alegada confissão da ré aos guardas que realizaram a sua prisão em flagrante, já que se trata de prova ilícita, pois não consta dos autos que ela foi previamente advertida de que não estava obrigada a responder as perguntas que lhe foram feitas. Conseqüentemente, a confissão extrajudicial durante abordagem policial, sem o aviso do direito ao silêncio, contraria o disposto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (nesse sentido, cf. TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500276-42.2019.8.26.0599, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. em 21/07/2022; TJ-

SP; Apelação Criminal nº 1500308-45.2020.8.26.0556, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. em 01/06/2021).

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, deixo de acolher a pretensão punitiva estatal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória e, conseqüentemente, ABSOLVO ROSILAINE FERNANDES DOS SANTOS da imputação constante da denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Formada a coisa julgada, determino a destruição das amostras de entorpecentes guardadas, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário, devendo a autoridade policial encaminhar a este Juízo o auto de incineração no prazo de 60 (sessenta) dias, cobrando-se na ausência.

Ademais, considerando que o valor apreendido foi encontrado junto com os entorpecentes, decreto seu perdimento em favor da União, com fundamento no artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. Proceda-se à transferência do valor ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad).

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 22 de novembro de 2022.

Érica Pereira de Sousa
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA